

RECURSO CÍVEL Nº 5063804-42.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: ANDREA GARCEZ DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

TRIBUTÁRIO. HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO (HRA). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL E DEMAIS TRIBUTOS. CARÁTER INDENIZATÓRIO, A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.467/17. NÃO INCIDÊNCIA DE IRPF. STJ. ERESP 1619117/BA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, reformando a sentença, para condenar a União a excluir a rubrica HRA recebida pela parte autora da base de cálculo do imposto de renda, bem como a restituir ao demandante os valores pagos a esse título, observado o quinquídio legal. O montante em questão será corrigido pela Taxa SELIC, conforme prevê o Enunciado 35 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, desde a data de cada pagamento indevido, excluindo-se qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora, pois a taxa SELIC abrange, a um só tempo, os juros e a correção monetária. O pagamento deverá se dar na forma do art. 17 da Lei nº 10.259/2001 e do Enunciado nº 52 das Turmas Recursais da Justiça Federal do Rio de Janeiro, obedecido ao teto dos JEF's, conforme dispõe o Enunciado 15 do FONAJEF. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, eis que recorrente vencedor. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2024.

5063804-42.2024.4.02.5101

510014678224 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5063804-42.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: ANDREA GARCEZ DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora, em face de sentença que julgou improcedente o seu pleito, que objetivava o reconhecimento da inexistência da relação jurídica tributária quanto a retenção de imposto de renda sobre o recebimento da parcela denominada "Hora Repouso Alimentação - HRA", bem como a restituição dos valores descontadas a esse título.

Em suas razões recursais, a parte autora alega que a indenização não corresponde a espécie alguma do acréscimo patrimonial previsto no art. 43 do CTN, posto que não configura contraprestação pelo serviço do empregado que já é remunerado pelo salário e pelas horas extras, mas sim uma indenização pela não fruição de um direito legalmente estabelecido (o da pausa para descanso e alimentação). Alega, ainda, que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência do Resp 1.619.117/BA, em 27 de novembro de 2019, firmou o entendimento de que a natureza jurídica da Hora Repouso Alimentação é remuneratória apenas até a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, quando passou a ter natureza indenizatória. Pugna, portanto, pela reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões apresentadas pela União, alegando se tratar de verba remunerária pela CLT, em razão do trabalho.

É o breve relatório. Passo a decidir.

In casus, o cerne da questão está em determinar se a natureza do pagamento feito à parte autora é de caráter indenizatório, ou remuneratório.

As verbas de natureza remuneratória, são caracterizadas pelo acréscimo patrimonial do indivíduo que as recebe, e por essa razão são contempladas pelo imposto de renda, na forma do artigo 43, *in verbis*:

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.

Por outro lado, as verbas de natureza indenizatória objetivam reparar um dano causado ao indivíduo, não caracterizando enriquecimento deste, por se tratar de valor compensatório da supressão de algum direito.

Ao analisarmos o artigo 71 da CLT, que trata da Hora Repouso Alimentação, ou HRA, verificamos que esta é caracterizada como verba de natureza indenizatória. Sob essa ótica, destaco a clara consequência fática da HRA: estar o trabalhador liberado do trabalho por um período de tempo, devendo ele ser indenizado caso essa liberação venha a ser suprimida pelo empregador, senão vejamos:

Art. 71 - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas.

*§ 4º A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, **de natureza indenizatória**, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência) (grifos nossos)*

A lógica que se apresenta é a seguinte: estando o trabalhador à disposição do empregador no momento em que deveria estar liberado, seja pelo motivo que for, há uma supressão de possibilidade de realização de atos outros que poderiam, estes sim, vir a adicionar ao autor valores a seu patrimônio. Qualquer acréscimo realizado à quantidade de tempo que o trabalhador deva permanecer no trabalho é um cerceamento de tempo que poderia ser utilizado de outra forma, formas que inclusive poderiam vir a gerar fontes de renda ao trabalhador.

Pois bem, quanto ao tema o STJ já havia firmado entendimento de que as parcelas relativas ao intervalo intrajornada e interjornada não usufruídos tem sua natureza salarial e incidem sobre elas a tributação, nas situações ocorridas antes da entrada em vigor da reforma trabalhista, a Lei 13.467/2017.

Assim, não possuindo natureza indenizatória, mas salarial, é possível a incidência da contribuição previdenciária e do imposto de renda, em princípio.

Quanto ao tema:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO (HRA). NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS 1. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de Hora Repouso Alimentação - HRA, prevista nos arts. 3º, II, da Lei 5.811/1972 e 71, § 4º, da CLT.

2. O acórdão embargado consignou que tal verba "[...] reveste natureza jurídica autenticamente indenizatória, pois seu escopo é recompor direito legítimo do empregado suprimido em virtude das vicissitudes da atividade laboral, assumindo perfil de genuína compensação, de verdadeira contrapartida a que o empregador está obrigado, por lei, a disponibilizar ao obreiro, em virtude da não fruição do direito ao intervalo para refeição e repouso que lhe é garantido, imprescindível ao restabelecimento do seu vigor físico e mental".

3. Partindo da premissa de que a Hora Repouso Alimentação - HRA possui natureza indenizatória, concluiu que sobre ela não deve incidir a contribuição previdenciária patronal (art. 22, I, da Lei 8.212/1991).

4. O julgado apontado como paradigma, por sua vez, assentou: "a 'Hora Repouso Alimentação - HRA' [...] é paga como única e direta retribuição pela hora em que o empregado fica à disposição do empregador", configurando, assim, "retribuição pelo trabalho ou pelo tempo à disposição da empresa e se submete à contribuição previdenciária, nos termos do art. 28 da Lei 8.212/1991".

5. É patente a similitude fática entre os acórdãos confrontados, bem como a divergência entre as soluções jurídicas adotadas em cada caso.

PRECEDENTES DA PRIMEIRA E DA SEGUNDA TURMA DO STJ 6. A Primeira Turma reconheceu que a HRA reveste natureza jurídica autenticamente indenizatória em mais um precedente: REsp 1.328.326/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Rel. p./acórdão Min.

Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26.5.2017.

7. Na Segunda Turma, prevalece a compreensão de que a Hora Repouso Alimentação - HRA possui natureza remuneratória, devendo incidir sobre ela a contribuição previdenciária patronal. Precedentes: AgInt no REsp 1.727.114/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.5.2019; AgInt no AREsp 1.122.223/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.8.2019; AgRg no REsp 1.449.331/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.5.2016; REsp 1.144.750/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25.5.2011; EDcl no REsp 1.157.849/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26.5.2011.

NATUREZA JURÍDICA DA HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO 8. A Hora Repouso Alimentação - HRA constitui verba paga ao trabalhador pela disponibilidade do empregado no local de trabalho, ou nas suas proximidades, durante o intervalo destinado a repouso e alimentação, conforme o art. 2º, § 2º, da Lei 5.811/1972.

9. O pagamento por essa "disponibilidade do empregado" é feito nos termos dos arts. 3º, II, da Lei 5.811/1972 e 71, § 4º, da CLT.

10. A Hora Repouso Alimentação - HRA é paga como única e direta retribuição pela hora em que o empregado fica à disposição do empregador. Ou seja, o trabalhador recebe salário normal pelas oito horas regulares e HRA pela 9ª (nona) hora, em que ficou à disposição da empresa.

11. Inexiste simplesmente supressão da hora de descanso, hipótese em que o empregado ficaria 8 horas contínuas à disposição da empresa e receberia por 9 horas (haveria "indenização" pela hora de descanso suprimida).

12. O empregado fica efetivamente 9 (nove) horas contínuas trabalhando ou à disposição da empresa e recebe exatamente por esse período, embora uma dessas horas seja paga em dobro, a título de HRA. Trata-se de situação análoga à hora extra: remuneração pelo tempo efetivamente trabalhado ou à disposição do empregador e sujeita à contribuição previdenciária.

13. Ao contrário do afirmado no acórdão embargado, a HRA possui nítida natureza remuneratória, submetendo-se à tributação pela contribuição previdenciária patronal, nos termos dos arts. 22, I, e 28 da Lei 8.212/1991.

14. Tratando da incidência da contribuição previdenciária sobre a HRA, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 1.039.689/RS (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.9.2017), afirmou: "Desse modo, não diverge o Tribunal a quo do entendimento da Corte no sentido da incidência de contribuição previdenciária patronal sobre verbas remuneratórias, conforme ficou deliberado no julgamento do RE nº 565.160/SC (Tema 20 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet). Verifico que, nessa decisão, a Corte se debruçou sobre o alcance da expressão 'folha de salários', contida no art. 195, I, 'a', da Constituição Federal, que é base de cálculo da exação em tela".

15. Em obiter dictum, impende ressaltar que a redação do art. 71, § 4º, da CLT foi alterada pela Lei 13.467/2017: "A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho".

16. A compreensão esposada abrange apenas os pagamentos e recolhimentos realizados antes da entrada em vigor da Lei 13.467/2017, uma vez que a nova redação do art. 71, § 4º, da CLT não foi objeto de discussão no presente caso.

CONCLUSÃO 17. Embargos de Divergência providos, para reconhecer a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre a Hora Repouso Alimentação - HRA, até a entrada em vigor da Lei 13.467/2017.

(EREsp 1619117/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 08/05/2020)

Todavia, como ressaltado no julgado acima, a Lei nº 13.467/2017, no artigo 71, §4º trouxe alterações na CLT e dispôs expressamente que o pagamento de intervalo intrajornada suprimido tem natureza indenizatória.

Assim, não incide o imposto de renda, a partir da entrada em vigor da Lei 13.467/17, sendo certo que qualquer momento anterior a ela, está submetido a incidência de IRPF.

Portanto, deve a sentença ser reformada.

Ante o exposto, voto por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, reformando a sentença, para condenar a União a excluir a rubrica HRA recebida pela parte autora da base de cálculo do imposto de renda, bem como a restituir ao demandante os valores pagos a esse título, observado o quinquídio legal. O montante em questão será corrigido

pela Taxa SELIC, conforme prevê o Enunciado 35 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, desde a data de cada pagamento indevido, excluindo-se qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora, pois a taxa SELIC abrange, a um só tempo, os juros e a correção monetária. O pagamento deverá se dar na forma do art. 17 da Lei nº 10.259/2001 e do Enunciado nº 52 das Turmas Recursais da Justiça Federal do Rio de Janeiro, obedecido ao teto dos JEF's, conforme dispõe o Enunciado 15 do FONAJEF. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, eis que recorrente vencedor. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. É como voto.